

1500636-53.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... o acusado praticando o delito de tráfico de drogas.

Havendo dúvidas acerca da existência de tráfico, deve-se decidir em favor do réu:

"TRÁFICO DE DROGAS - Não comprovação de atos de traficância - Circunstâncias da prisão que não indicam, por si, e de forma segura, atos de mercancia - Réu que sustenta ser usuário da droga - Recurso provido para desclassificar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500636-53.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500636-53.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2354985/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 22216250 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 3264/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2354985 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 3264/21/923 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2354985/2021 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DE OLIVEIRA DE MOURA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

GABRIEL DE OLIVEIRA DE MOURA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta do incluso inquérito policial que, em 31 de dezembro de 2021, por volta das 14h10min, na Rua Adalgisa Xixirri Guimarães Sá, nº 100, Parque Abílio Pedro, nesta cidade e comarca de Limeira, o acusado trazia consigo e guardava, com intuito de tráfico ilícito, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, 15 (quinze) porções de Erythroxylon coca, popularmente conhecida como cocaína, conforme auto de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar, para venda a consumo de terceiros.

Ao que se apurou, na ocasião supramencionada, o denunciado trazia consigo e guardava, em via pública, drogas para fins de comercialização.

Ocorre que policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, quando foram interceptados por um transeunte que informou que pela via pública havia um indivíduo traficando entorpecentes, indicando as características físicas do indivíduo.

Em patrulhamento pela via, os policiais se depararam com o denunciado, cuja características coincidiam com aquelas informadas pelo transeunte, o que motivou a abordagem. Em busca pessoal, os policiais encontraram nas vestes do denunciado três porções de cocaína e R\$25,00 (vinte e cinco reais), valores provenientes do tráfico.

Ainda, ao pé do banco em que o denunciado estava os policiais encontraram mais doze porções de cocaína idênticas àquelas que o denunciado trazia consigo.

Oferecida a denúncia, determinou-se a notificação do acusado para que apresentasse defesa preliminar (fls. 110/111), que veio aos autos (fls. 115/116).

A denúncia foi recebida em 26 de outubro de 2022 (fls. 121).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, com interrogatório do acusado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Alegações finais orais do Ministério Público e da Defensoria Pública (mídia).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, rejeito a tese preliminar arguida pela Defesa, fundada na suposta ilicitude da busca pessoal por ausência de motivação idônea, pois, conforme relatado pelos policiais militares em audiência, além da denúncia anônima recebida em relação ao crime de tráfico de drogas no local da prisão, houve encontro de entorpecentes e dinheiro com o acusado em local conhecido pela traficância ilícita, cabendo salientar que o denunciado confirmou ter sido flagrado por um morador da região consumindo drogas antes da abordagem, restando, pois, configurada a fundada suspeita que amparou a diligência (artigo 244 do CPP).

Não há outras preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 17/18), auto de exibição e apreensão (fls. 19), laudo pericial com resultado positivo para cocaína (fls. 58/60), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria, por sua vez, é duvidosa, não havendo prova suficiente para se imputar ao réu o crime de tráfico de drogas.

O policial militar Roberto Burger contou que no dia dos fatos foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de tráfico no bairro Abílio Pedro. A denúncia trazia as vestimentas e não dava mais detalhes. O local é uma praça e é conhecida nos meios policiais como ponto de venda de drogas. No ponto de ônibus ali perto

avistaram de imediato o acusado, com as mesmas vestimentas indicadas na denúncia. Em vistoria localizaram três porções de cocaína no elástico de cueca e mais vinte e cinco reais em dinheiro. No pé do ponto de ônibus, havia mais doze porções de cocaína. Indagado, ele confirmou ser traficante. Não se recorda se havia mais pessoas no ponto de ônibus, chovia no momento da abordagem. Assim que chegaram, já realizaram a abordagem de imediato. Não conhecia o acusado até então. Não fizeram qualquer campana (mídia).

O policial militar Nicolas Rodrigo Gentil disse que faziam patrulhamento quando o COPOM irradiou denúncia anônima de tráfico de drogas. As características do traficante foram repassadas, não havia outros detalhes. No ponto de ônibus viram o réu com as características indicadas. Seu parceiro Roberto localizou drogas no elástico da cueca do réu, assim como certa quantia em dinheiro. Em vistoria nas imediações, perto de um banco, localizaram mais porções de cocaína. Indagado, ele confessou a traficância. Havia uma senhora de idade aguardando o ônibus. Não viram o denunciado conversando com qualquer usuário antes da abordagem. Não conhecia o réu até então. Não fizeram campana antes da prisão (mídia).

Em Juízo, o réu disse que tem 20 anos. É trabalhador rural. É casado e mora com a esposa. No dia em questão, estava no local porque iria comprar cocaína. Tinha cinquenta e cinco reais antes da abordagem. Comprou três porções. O vendedor foi para o banco da praça. Estava ele e uma senhora no ponto de ônibus. A viatura da polícia passou mais de uma vez e ele continuou no banco. Não sabia que tinham drogas no ponto de ônibus. Foram localizadas três porções de cocaína quando revistado. Negou qualquer confissão aos guardas. Tinha vinte e cinco reais em seu poder. Não estava traficando, apenas iria consumir aqueles entorpecentes. Os guardas acharam porções escondidas no ponto de ônibus, mas não tinha visto essas drogas e não tem qualquer vinculação com tais entorpecentes. Viu uma roupa de bebê perto das drogas, mas não desconfiou de nada. Estava conversando com uma senhora de idade no momento da abordagem. Sabia que o local é um ponto de venda de drogas. Não conhece o rapaz que vende entorpecentes e já tinha ido algumas vezes naquele ponto de tráfico. Naquela época era viciado em cocaína. Quando esperava a chuva passar, fez um consumo de cocaína e viu uma mulher olhando pela varanda de uma casa, acredita que foi ela quem fez a denúncia anônima (mídia).

Esta foi a prova oral colhida em audiência.

No tocante à finalidade com que o acusado trazia a substância entorpecente apreendida, não restou comprovada cabalmente ser a sua intenção entregar entorpecentes ao consumo de terceiros. A quantidade de drogas encontradas em seu poder não era incompatível com o uso e o réu confirmou ser usuário de cocaína ao ser interrogado judicialmente.

Por outro lado, os policiais militares não presenciaram qualquer ato de tráfico. Contra o denunciado pesa apenas o fato dele ter sido surpreendido em poder de três porções de cocaína, a denúncia anônima genérica e o local ser conhecido como ponto de venda, não havendo qualquer apreensão de outros objetos em seu poder ligados ao narcotráfico.

É sabido que os usuários, na maioria das vezes, adquirem drogas em locais onde o tráfico é praticado com habitualidade. Também não é anormal que eles carreguem drogas em porções individuais, máxime quando não são em grande número, como no caso dos autos, sem qualquer ato típico de venda de drogas flagrado pelos agentes públicos antes da prisão em flagrante.

O simples fato dos guardas terem encontrado dinheiro com o réu não comprova que a quantia monetária tenha origem na atividade ilícita que lhe é imputada, ainda mais porque é diminuta.

Não bastasse, os demais entorpecentes foram apreendidos no ponto de ônibus, nas proximidades do local da abordagem, conhecido nos meios policiais por ser ponto de venda de drogas.

Logo, incabível atribuir a propriedade dos referidos entorpecentes ao acusado, tendo em vista que não foi visto manuseando essas porções e nem se aproximando do local em que foram localizadas, não havendo sequer campanha realizada pelos agentes públicos antes da abordagem e custódia.

Nesse cenário, não se pode considerar a confissão informal do acusado, uma vez que viola o direito de silêncio, bem como o fato de ter negado com veemência a acusação ao ser interrogado judicialmente.

Diante de um arcabouço jurídico igual ao que se apresenta, preocupado com a proteção da inocência presumível de todos (cf. artigo 5º, inciso LVII, da CF), que impõe ao juiz a livre apreciação da prova, não podendo dar exclusivo valor nos elementos informativos colhidos durante a investigação policial (cf. artigo 155 do CPP), sem vínculo a laudo pericial (cf. artigo 182 do CPP) ou mesmo à confissão do acusado (cf. artigo 197 do CPP), parece ser indispensável que o juízo penal condenatório seja vazado com prova indubitável e cristalina, inequívoca e concludente mesmo, sem deixar margem a dúvidas.

No caso desta ação penal que se discute, parece visível que a prova colhida é insuficiente para compor um adequado juízo de reprovação penal da conduta imputada ao acusado. Aliás, ainda quanto a isso, os policiais militares não foram capazes de sustentar que surpreenderam o acusado praticando o delito de tráfico de drogas.

Havendo dúvidas acerca da existência de tráfico, deve-se decidir em favor do réu:

"TRÁFICO DE DROGAS - Não comprovação de atos de traficância - Circunstâncias da prisão que não indicam, por si, e de forma segura, atos de mercancia - Réu que sustenta ser usuário da droga - Recurso provido para desclassificar para uso próprio (voto nº 39073)". (TJSP; Apelação Criminal 0006634-19.2015.8.26.0153; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cravinhos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/03/2019; Data de Registro: 25/03/2019).

"APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recursos ministerial e defensivo. Réu surpreendido na posse da droga apreendida. Palavras dos policiais militares que merecem credibilidade. Absolvição inviável. Possibilidade de desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 em vista da ausência de comprovação da destinação ao tráfico. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Acusado primário e menor relativo. Pena de advertência que se mostra adequada e suficiente. Prejudicada a análise do pleito do Ministério Público de reconhecimento do crime de associação para o tráfico. Recurso defensivo parcialmente provido e recurso ministerial improvido." (TJSP; Apelação Criminal 0000471-84.2018.8.26.0616; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro: 09/10/2019).

"Apelação. Tráfico de entorpecentes. Provimento para desclassificar o delito pelo qual foi condenado para o do artigo 28 da Lei de Drogas, aplicando-se a pena de advertência sobre os efeitos da droga". (TJSP; Apelação Criminal 0001189-48.2018.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 08/10/2019).

E afasto a inconstitucionalidade do tipo penal do artigo 28 da Lei de Drogas e tal não se justifica mediante o reconhecimento de que a tipicidade dessa conduta se vincula às propriedades da droga e ao risco social e à saúde pública, e não à

lesividade em concreto.

Ou seja, em se tratando de crime de perigo presumido ou abstrato, em que a pequena quantidade de substância entorpecente é própria do tipo incriminador, a conduta do réu viola a norma que visa a evitar exatamente o uso.

Considera-se ainda que o direito constitucional à privacidade do indivíduo não se sobrepõe ao interesse coletivo de proteger a saúde pública.

No mais, a decisão do Supremo Tribunal Federal ainda não é definitiva e o assunto está pendente de discussão naquela corte.

Conforme já restou decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“APELAÇÃO. USO PESSOAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONSTITUCIONALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE. CONFISSÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. Não há inconstitucionalidade a ser reconhecida quanto ao crime de posse de substância entorpecente, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, que é direito difuso por excelência e que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome substâncias entorpecentes, vale dizer, sem ferir o direito à intimidade, previsto no art. 5º, X, da CF. Inteligência da Doutrina e da Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Por sinal, em que pese o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ter se manifestado pela existência de Repercussão Geral, a tese da constitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343/06, ainda não foi dirimida, devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da constitucionalidade do crime de uso de substância entorpecente. Inteligência da Doutrina de Vicente Greco Filho e Gustavo Octaviano Diniz Junqueira. Precedentes do TJSP (Ap. 0026791-41.2009.8.26.0050 9ª C Rel. Des. Sérgio Coelho j. 11.09.2014 DO 18.09.2014; 0031627-94.2010.8.26.0576 9ª C Rel. Des. Penteado Navarro j. 21.11.2013 DO 22.11.2013 e Ap. 0030836-79.2009.8.26.0344 1ª C Rel. Des. Marco Nahum j. 21.02.2011 DO 22.02.2011). (...) Improvimento ao recurso defensivo”. (TJSP; Apelação 0024759-53.2014.8.26.0320; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017).

Assim sendo, todas essas circunstâncias somadas determinam a desclassificação, com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal, razão pela qual desclassifico a conduta do réu para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de DESCLASSIFICAR a conduta de GABRIEL DE OLIVEIRA DE MOURA, qualificado nos autos, para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias do fato, além da pouca quantidade de droga apreendida e a confissão judicial, aplico-lhe a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, prevista no art. 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

O réu já foi advertido em audiência.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA